

1502130-63.2019.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1502130-63.2019.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502130-63.2019.8.26.0537

2019/002093

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARLON DOS SANTOS CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

MARLON DOS SANTOS CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 14, "caput", da Lei n.º 10.826/03, porque no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 06:45 horas, na Rua Serra do Tumucumaqui e na Rua Serra de Macaé, altura do nº 628, Centro, detinha, adquiriu, portava, transportava e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver da marca Ina, de calibre 32, de numeração 14020, municiado com 3 (três) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi concedida liberdade provisória ao réu na audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares, em 11.10.19 (fls. 22/24).

O M.P não propôs acordo de não persecução penal (fls. 55). Recebida a denúncia em 06.05.21 (fls. 64), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 97/98). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto às faltantes, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.ª Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia.

O Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena-base no mínimo legal, que seja considerada a atenuante da confissão, primariedade, regime aberto e a substituição da pena por privativa de liberdade por

restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 08), o a réu confessou a prática do crime. Declarou que é usuário de drogas e estava há três dias sem dormir, consumindo entorpecentes. Afirmou que possuía o revólver apreendido consigo há algum tempo. Falou que, por estar sob efeito das drogas, pensou em praticar roubos com a arma de fogo. Disse que, antes de praticar qualquer roubo, foi abordado pelos policiais e conduzido à delegacia. Informou que dispensou a arma durante a fuga a fim de tentar fugir da prisão em flagrante. Declarou estar arrependido.

Em juízo, confessou que estava com a arma para sua proteção, porque foi ameaçado pela perda de um carro. Comprou a arma de um conhecido que ia viajar. Não tinha documentos da arma. Tem um processo por uso de drogas. Não conhecia os policiais. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02/03), disseram que estavam em patrulhamento da ronda escolar quando avistaram o réu próximo a uma escola na Rua Serra do Tumucumaqui. Relataram que perceberam que o réu ajustava algo em sua cintura e resolveram abordá-lo. Falaram que o réu empreendeu fuga ao ver que seria abordado. Afirmaram que durante a fuga o réu dispensou uma arma de fogo no interior de uma residência localizada na Rua Serra de Macaé, n.º 628. Declararam que lograram deter o réu e enquanto o revistavam solicitaram apoio de outra viatura. Informaram que o proprietário da referida residência comunicou ao COPOM dizendo que uma arma de fogo havia sido jogada dentro de sua casa. Disseram que na residência localizaram e apreenderam um revólver "calibre .22, com numeração suprimida e três munições íntegras"(sic) e que o réu foi conduzido ao distrito policial.

Luís Guilherme (policial), em juízo, afirmou que avistaram o réu perto da escola, ajustando algo na cintura, e quando percebeu que ia ser abordado se evadiu. O COPOM informou que alguém tinha jogado arma numa residência. O réu falou que era usuário, e arma lhe pertencia e não apresentou documentos. Ficou com o réu, mas não se lembra se foi seu parceiro ou outra viatura que localizou a arma. A arma era um revólver e estava municiado.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Rodrigo. Viu que o réu tirou algo da cintura e jogou algo na residência. O morador já tinha ligado para o 190 informando que um homem jogou a arma no portão que era vazado. Narrou que pegou a arma e foram para o DP. O réu falou que a arma era dele e ia praticar roubos. A arma era um revólver calibre 32, municiado, raspada. Não conhecia o réu anteriormente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia: As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

A arma estava municuada e foi dispensada pelo réu em uma residência, conforme declarações dele e dos policiais.

A materialidade do crime de porte ilegal está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão da arma e munições (fls. 04/05) e pelo laudo pericial que comprovou que a arma de fogo é apta para efetuar disparos (fls. 59).

Diante das diversas campanhas de desarmamento é fato público e notório que ter arma sem porte e estar com ela em via pública caracteriza crime de porte ilegal de arma.

"A alegação de que o agente portava arma devido ao medo de ser vítima de crimes, uma vez que é obrigado a transitar por locais perigosos, não justifica a falta do porte, nem exclui a ilicitude da conduta. Se assim não fosse, o tipo penal quase nunca teria aplicação, ficando ao talante do subjetivismo das alegações do agente" (Estatuto do Desarmamento, Fernando Capez, Saraiva, 3.ª ed. 2005, p. 122).

Incabível o princípio da bagatela, mesmo porque se trata de crime de perigo

abstrato, bastando a lesividade presumida da conduta, e diante da pena mínima legalmente imposta.

Assim, considerando que confessou o réu confessou nas duas fases que trazia consigo a arma de fogo, que não tinha porte, e a dispensou tentando evitar o flagrante, impõe-se a condenação, que segundo consta dos autos possui antecedentes (fls. 20/21 - proc. 40596-51.2015).

Observo que a condenação anterior do réu é pelo art. 28 da Lei n.º 11.343/06, a qual não está apta a configurar reincidência, vez que se trata de infração punida com medidas diversas da prisão, equiparada às contravenções penais, não geradoras de reincidência.

Nesse sentido, decidiu o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, reincidência. 4. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade. 5. Nesse sentido, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, tendo em vista que a reincidência foi o único fundamento para não aplicar a benesse e tendo sido afastada a agravante, de rigor a aplicação da redutora. 7. Quanto ao regime e a substituição, tratando-se de réu primário, condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, com a análise favorável das circunstâncias judiciais, além da não expressiva quantidade de droga - 7,2 g de crack -, o paciente faz jus ao regime aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, assim como resulta cabível a conversão da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para conceder a ordem para redimensionar a pena do paciente, fixar o regime aberto

e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (HC 453.437/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes criminais fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, à razão mínima. Diminuo a pena de 4 meses de reclusão e 1 dia-multa, em razão da confissão extrajudicial.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto (art. 33, § 2.º, letra "c", do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, CONDENO MARLON DOS SANTOS CARVALHO à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, com início no REGIME ABERTO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 14, "caput", da Lei n.º 10.826/03.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimirem os crimes. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal), ressalvado o disposto no art. 46, § 4.º, do Código Penal, devendo em razão da detração penal ser abatido o tempo que ficou preso.

A substituição é cabível, porque o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, § 3.º, do Código Penal) e socialmente recomendável, uma vez que a condenação anterior foi à pena de advertência sobre os efeitos das drogas (fls. 20) e que o crime não envolve violência ou grave ameaça, o que denota que merece uma oportunidade para demonstrar sua responsabilidade para cumprir o benefício.

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e que após as substituições legais foram cominadas apenas penas restritivas de direitos e multa. Observo que as munições apreendidas foram utilizadas em prova de tiro, conforme consta nos laudos periciais (fls. 62), pelo que não há providências a serem determinadas.

Tendo em vista que a arma de fogo apreendida possui numeração, expeça-se edital nos termos das NCGJ.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 05 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA